

1500590-36.2021.8.26.0431

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MATHEUS CURSINO VILLELA

Comarca: Pederneiras

Foro: Foro de Pederneiras

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 16/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2191982/2021 - DEL.SEC.BAURU PL SUB-REG, 19070825 - DEL.SEC.BAURU PL SUB-REG,

395/21/004 - DEL.SEC.BAURU PL SUB-REG, 2191982 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pederneiras

Foro de Pederneiras

1ª Vara

Rua: Belmiro Pereira, S-367, Pederneiras-SP - cep 17280-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500590-36.2021.8.26.0431 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500590-36.2021.8.26.0431

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2191982/2021 - DEL.SEC.BAURU PL SUB-REG, 19070825 - DEL.SEC.BAURU PL SUB-REG,

395/21/004 - DEL.SEC.BAURU PL SUB-REG, 2191982 - DEL.POL.PEDERNEIRAS, 395/21/004 -

DEL.POL.PEDERNEIRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS FELIPE DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MATHEUS CURSINO VILLELA

Vistos.

MATHEUS FELIPE DE SOUZA, qualificado às fls. 24/26, está sendo processado por suposta infração ao artigo 33, "caput", e § 1º, inciso II, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo consta da Denúncia, no dia 15 de julho de 2021, por volta das 18h10min., na Rua Reinaldo Guerra, nº 1000, bairro Cidade Nova, nesta cidade e Comarca de Pederneiras, , estaria trazendo consigo, para fins de comercialização, 07 (sete) pedras de "crack", com massa líquida total de 1,35 g (um grama e trinta e cinco centigramas), bem com, na sua residência situada na mesma rua, do numeral 935, estaria guardando, para fins de tráfico, 07 (sete) porções de "cocaína", com peso líquido total de 1,43 g (um grama e quarenta e três centigramas), e semeando ou cultivando plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na oportunidade, o réu foi detido em flagrante e após análise dos pressupostos legais, frente às circunstâncias até então evidenciadas, deliberou-se pela concessão da liberdade provisória mediante a imposição das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal (fls. 59/61).

Denúncia recebida à fl. 108.

O réu foi citado (fl. 123) e apresentou resposta à acusação (fls. 124/127).

Laudo pericial às fls. 84/88.

Folha de antecedentes às fls. 119/121.

Realizada a audiência de instrução, na qual foram ouvidas as testemunhas e ao final o réu foi interrogado.

As partes ofertaram alegações finais orais.

O Ministério Público pugnou pela condenação do réu, nos exatos termos da denúncia, ao passo que a defesa requereu a absolvição do acusado por insuficiência de provas, e caso seja condenado, sustentou pela desclassificação do delito para o crime previsto no artigo 28, "caput", da Lei de Drogas e pela consequente aplicação da pena mínima e seus consectários legais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Procede em parte a ação penal.

A materialidade está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 7/9, Auto de Exibição e Apreensão de fls. 10/11, laudo pericial de fls. 84/88, que confirmou a natureza das substâncias entorpecentes recolhidas na posse do réu, bem assim pela prova oral.

De igual modo, a autoria é certa.

Convém asseverar, contudo, que não há elementos suficientes capazes de comprovar acerca da legalidade do ingresso dos policiais na residência do acusado. Isso porque, a despeito da narrativa dos castrenses em solo policial de que tenham sido autorizados a adentrar no imóvel pelo próprio acusado e por sua mãe, posteriormente, ouvido em juízo, o policial Arilson Fornazari disse que a mãe do réu deixou que entrassem na residência dele, sob o fundamento de que era ela quem pagava o aluguel, e por outro lado, não foi seguro em afirmar, categoricamente, a respeito da autorização pelo réu.

De assinalar, nessa esteira, que a Constituição Federal é clara em determinar, como regra geral, a anuência do morador para o ingresso em seu domicílio. Em cotejo com os fatos narrados, no entanto, é possível notar que para além da ausência de qualquer comprovante escrito ou gravação que evidencie tal autorização, o policial militar, ouvido em audiência, deu a entender que apenas a genitora do acusado anuiu com o ingresso no imóvel, e mesmo assim, não foi convincente o bastante.

Além do mais, o réu foi peremptório em negar ter concordado com a entrada dos castrenses em sua residência, dizendo que fugiu da abordagem policial, pois ficou com medo.

Nesse caso, caberia ao órgão acusador o ônus de afastar qualquer dúvida acerca da controvérsia, o que no caso em comento, não se verificou, eis que sequer foi arrolada como testemunha a genitora do acusado para que, então, confirmasse tal anuência, e portanto, aplicável a teoria da perda de uma chance, como já decidiu a 5ª Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante se extrai da ementa a seguir:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A HOMICÍDIO TENTADO. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA SUA REJEIÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. TESTEMUNHO INDIRETO (HEARSAY TESTIMONY) QUE NÃO SERVE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. OFENSA AO ART. 212 DO CPP. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO, PELA POLÍCIA, DAS TESTEMUNHAS OCULARES DO DELITO, IMPOSSIBILITANDO SUA OUVIDA EM JUÍZO. FALTA TAMBÉM DO EXAME DE CORPO DE DELITO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III E VII, E 158 DO CPP. DESISTÊNCIA, PELO PARQUET, DA OUVIDA DE DUAS TESTEMUNHAS IDENTIFICADAS E DA VÍTIMA. GRAVES OMISSÕES DA POLÍCIA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE RESULTARAM NA FALTA DE PRODUÇÃO DE PROVAS RELEVANTES. TEORIA

DA PERDA DA CHANCE PROBATÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DO DEPOIMENTO DO REPRESENTADO. EVIDENTE INJUSTIÇA EPISTÊMICA.[grifei]. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE ABSOLVER O RECORRENTE. (AREsp 1940381 / AL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2021/0242915-6. Ministro Relator: RIBEIRO DANTAS. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Data do Julgamento: 14/12/2021. Data da Publicação/Fonte: DJe 16/12/2021)

Frise-se que a mera apreensão dos entorpecentes na posse do réu não permitem concluir, por si só, acerca da necessidade de ingresso no domicílio do acusado sem autorização. Há que se ter em mente a análise do caso concreto e mesmo assim, com ressalvas e valendo-se documentação apta a demonstrar acerca da devida concordância do morador, na esteira do quanto determinado pela Corte Superior, no emblemático HC 598.051/SP, que fixou parâmetros para a entrada dos agentes de segurança pública na residência do réu. Vale colacionar, nesta senda, trecho do aresto supramencionado:

[...] 7.1. Ante a ausência de normatização que oriente e regule o ingresso em domicílio alheio, nas hipóteses excepcionais previstas no Texto Maior, há de se aceitar com muita reserva a usual afirmação - como ocorreu no caso ora em julgamento - de que o morador anuiu livremente ao ingresso dos policiais para a busca domiciliar, máxime quando a diligência não é acompanhada de documentação que a imunize contra suspeitas e dúvidas sobre sua legalidade. 7.2. Por isso, avulta de importância que, além da documentação escrita da diligência policial (relatório circunstanciado), seja ela totalmente registrada em vídeo e áudio, de maneira a não deixar dúvidas quanto à legalidade da ação estatal como um todo e, particularmente, quanto ao livre consentimento do morador para o ingresso domiciliar. Semelhante providência resultará na diminuição da criminalidade em geral - pela maior eficácia probatória, bem como pela intimidação a abusos, de um lado, e falsas acusações contra policiais, por outro - e permitirá avaliar se houve, efetivamente, justa causa para o ingresso e, quando indicado ter havido consentimento do morador, se foi ele livremente prestado. [...] (HC 598051 / SP HABEAS CORPUS 2020/0176244-9. Ministro Relator: ROGERIO SCHIETTI CRUZ. Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA. Data do Julgamento: 02/03/2021. Data da Publicação: DJe 15/03/2021. RSTJ vol. 261 p. 1043)

Logo, é forçosa a conclusão acerca da ilegalidade da busca domiciliar, porquanto inexistente autorização judicial prévia ou comprovada concordância do morador para o ingresso em sua casa. Por consequência, inadmissível a prova daí decorrente, tais como a apreensão de um pé de maconha e dos eppendorfs supostamente encontrados nos fundos da casa, remanescendo apenas a análise dos demais elementos colhidos em momento anterior, quando da localização de uma sacola contendo algumas pedras de "crack", porquanto independentes das diligências efetuadas a posteriori.

Senão vejamos.

O policial militar Arilson Fornazari, relatou, em juízo, que na data dos fatos estava em patrulhamento pelo Bairro Cidade Nova, quando o réu visualizou a viatura, saiu correndo e jogou uma sacola branca. Nesta embalagem, estavam as pedras de "crack". Foram até a residência do réu e a mãe informou que ele não mais residia ali e levou a equipe até o local de moradia. O réu disse que a droga era dele e que se destinava à venda. Não tinha ciência que o réu estava traficando.

A testemunha de defesa Victor Hugo Rangel Monteiro disse que conhece o réu do rolê. Conhece ele de vista. É usuário e o réu também. De vez em quando se trombam e fumam um baseado. Até onde sabe, o réu é apenas usuário de drogas. Já viu o réu usar cocaína, maconha e "crack". Não conhece a residência do réu. Sabe que ele já trabalhou na Paschoalotto em Bauru.

Indagado pela autoridade policial, o réu admitiu estar praticando o tráfico de drogas e afirmou ser o proprietário dos entorpecentes apreendidos, salvo do pé de maconha. Informou, ainda, que vendia cada pedra de "crack" e porção de cocaína por R\$ 10,00 (dez reais) e que possuía uma dívida, e por isso, estava comercializando tais entorpecentes.

Ouvido em juízo, alegou que é apenas usuário e que não estava traficando. Não autorizou o ingresso na residência. Ficou com medo da abordagem e por isso fugiu.

Não sabe se a mãe autorizou a entrada na residência. Era a mãe quem pagava o aluguel. O pé de maconha era dele e plantou para usar porque compensava mais. Já estava plantado lá antes de se mudar, quem morava lá era um amigo dele. Estava desempregado na época. Já cometeu alguns delitos para usar e por isso a mãe o mandou embora de casa. É usuário de maconha, cocaína e "crack". Ressalto, contudo, que a negativa do réu em juízo, de forma a retratar-se de suas declarações prestadas em sede policial não convencem, vez que naquela oportunidade, informou, inclusive, o preço pelo qual cobrava por cada porção do entorpecente e esclareceu o motivo pelo qual estava traficando, dizendo que havia contraído uma dívida.

Vale lembrar que o próprio acusado mencionou que na época, estava desempregado, o que reforça a tese de que estava comercializando drogas com o intuito de sustentar o vício.

Os policiais militares que efetuaram sua prisão também foram unânimes em relatar que o réu fora surpreendido em atitude suspeita e que ao visualizar a viatura, evadiu-se e dispensou uma sacola branca contendo sete pedras de "crack". Disseram, ainda, que o réu posteriormente confessou que estava vendendo tais entorpecentes. Nessa quadra, não merece acolhida a tese defensiva acerca da parcialidade dos agentes da lei, mesmo porque, sequer conheciam o acusado, muito embora o policial Fornazari tenha informado, em juízo, que já fizera algumas abordagens no réu. Fato é que o réu sequer possui antecedentes criminais que possam levar a crer que tivessem os policiais a intenção de persegui-lo e atribuir-lhe conduta criminosa de tamanha gravidade.

Além do mais, o laudo pericial de fls. 84/88 foi conclusivo em indicar que as substâncias dispensadas pelo réu antes de sua fuga se tratavam de cocaína em forma de "crack", substâncias estas extremamente viciantes e prejudiciais à saúde. Semelhante raciocínio se extrai quanto à alegada indução dos policiais no sentido de fazerem com que o réu confessasse a prática do tráfico, porquanto a despeito de não estar sendo assistido por advogado quando de seu interrogatório prestado na delegacia, as demais provas dão conta de evidenciar a conduta delitiva, tanto pelo testemunho harmônico dos policiais militares, como pela apreensão das drogas, circunstâncias que confirmaram exatamente o que dissera o acusado em solo policial. Não comporta cabimento, ademais, a desclassificação do delito, para o tipo previsto no artigo 28, "caput", da Lei 11.343/06, na medida em que não obstante a pequena quantidade de drogas, restou demonstrado que estavam destinadas à comercialização. Cabe apontar, neste particular, que o fato de ser viciado em entorpecentes não afasta a prática do tráfico, muito pelo contrário, ambas as condutas se complementam. Veja-se que, conforme já consignado, o réu informou perante a autoridade policial que havia contraído uma dívida pela aquisição de drogas, e por este motivo, estava vendendo tais substâncias.

De rigor, portanto, o decreto condenatório apenas quanto ao episódio em que foram localizadas as substâncias entorpecentes, jogadas pelo réu em momento anterior à sua fuga.

Em observância ao critério trifásico da dosimetria da pena, passo a dosá-la.

De salientar, na primeira fase, que o réu é primário e não recai contra si nenhuma circunstância desabonadora de sua conduta, e além disso, pequena quantidade de droga foi encontrada em seu poder, razão pela qual fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Anoto que a despeito da menoridade penal, não há como reduzir a sanção aquém do mínimo legal, a rigor do que dispõe a Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Desta feita, mantenho a reprimenda nos mesmos moldes estabelecidos na fase anterior.

Na derradeira etapa, por outro lado, estão presentes todos os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado, tendo em vista a primariedade, os bons antecedentes, e não restar comprovada a dedicação do réu a atividades criminosas, nem tampouco fazer parte de organização criminosa.

Sendo assim, reduzo a pena ao máximo de 2/3, perfazendo na sanção de 1 (um) ano e 8

(oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Diante do quantum da pena e da primariedade, é cabível o regime aberto para o seu cumprimento.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em limitação de fim de semana, e prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, a ser revertido em prol de instituição a ser definida pelo juízo competente para a execução da pena.

Fixo cada dia-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, para os fins de CONDENAR o réu MATHEUS FELIPE DE SOUZA, qualificado às fls. 24/26, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, SUBSTITUÍDA por duas restritivas de direitos, consistentes em limitação de fim de semana, pelo mesmo período da pena; e prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, a ser revertido em prol de instituição a ser definida pelo juízo competente para a execução da pena ; e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal; e para ABSOLVÊ-LO das condutas previstas no artigo 33, § 1º, inciso II, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Defiro ao réu o direito de apelar em liberdade por estarem mantidas as circunstâncias que levaram a que respondesse ao processo até aqui em liberdade. Diante do regime ora fixado, revogo as medidas cautelares impostas às fls. 59/61. Anote-se.

Condeno o sentenciado ao pagamento das custas processuais, observado o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Defiro a expedição de certidão de honorários no grau máximo permitido na tabela da OAB ao procurador do réu.

Com o trânsito em julgado desta sentença: i) comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD (NSCGJ, artigos 393, V e §1º e 398) e ao TRE (NSCGJ, artigo 398) e expeça-se guia de recolhimento definitiva; ii) determino a destruição das amostras guardadas para contraprova, devendo a Z. Serventia comunicar a Autoridade Policial para tanto (art. 525, NSCGJ).

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Pederneiras, 15 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA